

1500106-52.2022.8.26.0280

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Comarca: Itariri

Foro: Foro de Itariri

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 26/10/2022

... para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Narra que, na data dos fatos, policiais civis, durante investigação para combater tráfico ilícito de entorpecentes, identificaram a movimentação de venda de entorpecentes pelos acusados NILTON e JÉSSICA. Após observarem toda movimentação, os policiais avistaram que JÉSSICA pegou uma bicicleta e saiu do local. Foram em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itariri

Foro de Itariri

Vara Única

Rua Engenheiro José Claret de Toledo Goulart, 41, Itariri (SP) - cep 11760-000

1500106-52.2022.8.26.0280 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500106-52.2022.8.26.0280

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JÉSSICA BATISTA RIBEIRO FRANCISCO e outros

Réu Preso

Juiz Substituto: Dr. ALEXANDRE MORON DE ALMEIDA

Relatório

Cuida-se de ação penal pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO contra JÉSSICA BATISTA RIBEIRO FRANCISCO, PEDRO HENRIQUE MOTA DE SOUZA e NILTON PINHEIRO JUNIOR, imputando-lhes a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06.

Sustenta a denúncia que, no dia 11 de abril de 2022, por volta das 18h40min, na Rua do Comércio, nº 193, Praça, nesta cidade e comarca de Itariri, os acusados guardavam, traziam consigo e mantinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para entrega a consumo de terceiros, 1 porção de maconha e 15 eppendorfs de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 15/16 e auto de constatação preliminar de fls. 17/18.

Sustenta ainda que os acusados, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, associaram-se para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas.

Narra que, na data dos fatos, policiais civis, durante investigação para combater tráfico ilícito de entorpecentes, identificaram a movimentação de venda de entorpecentes pelos acusados NILTON e JÉSSICA. Após observarem toda movimentação, os policiais avistaram que JÉSSICA pegou uma bicicleta e saiu do local. Foram em seu encalço e verificaram que ela se dirigiu ao imóvel localizado na Rua Nossa Sra. do Monte Serrat, nº 164. A acusada Jéssica entrou no imóvel e saiu com uma sacola plástica dirigindo-se novamente à praça, sentando-se ao lado de Nilton, para vender novos entorpecentes. Assim, constatando que Nilton e Jéssica dariam continuidade ao tráfico de drogas naquele local, os policiais realizaram a abordagem e encontraram

com Nilton uma porção de maconha. Ato contínuo, dirigiram-se novamente até o local em que Jéssica havia retirado a sacola plástica que continha a droga. Ao chegarem ao local, identificaram o acusado Pedro e localizaram 15 eppendorfs de cocaína. No interior da casa, foram apreendidos caderno com anotações de controle das vendas dos ilícitos e material utilizado para o preparo de drogas. Com Jéssica, foram encontrados R\$ 90,00 guardados no sutiã. Com Nilton ainda encontraram R\$ 79,00 oriundos do tráfico de drogas.

Laudo químico-toxicológico a fls. 149/151 e laudos cautelares a fls. 257/258, 263/265 e 266/268.

Notificados (fls. 162, 164 e 166), a defesa prévia, pelo defensor dativo, foi juntada (fls. 189/197).

Advogado constituído por NILTON ingressou a fls. 215/216.

A denúncia foi recebida (fls. 226/227).

Em audiência, foram colhidos os depoimentos das testemunhas e realizado o interrogatório, em que JESSICA nega a autoria delitiva, dizendo que estava apenas com uma porção, que compartilhou com NILTON enquanto aguardava o transporte para Pedro de Toledo, e não sabia que havia droga ou documento seu na casa de PEDRO; NILTON nega a traficância e sequer conhecer PEDRO, mas diz saber que JESSICA estava com uma porção de maconha que iriam consumir; e PEDRO diz que a droga dentro de sua residência era para seu consumo próprio, tendo adquirido naquele dia e consumido alguns pinos, entregando espontaneamente todas as porções aos policiais.

Em alegações finais, o Ministério Público pugna pelo parcial acolhimento da pretensão acusatória, com a absolvição em relação à associação para o tráfico, mas com a condenação pelo crime de tráfico ante a suficiência do depoimento policial, valorando-se na fixação da pena os maus antecedentes e a reincidência de NILTON e de PEDRO, afastando-se a figura privilegiada e com regime inicial fechado, mas, quanto a JESSICA, reconhecendo o privilégio com os consectários cabíveis à espécie. A defesa técnica de PEDRO e JESSICA pugna pela absolvição dos acusados, ressaltando os elementos probatórios indicativos de se tratar PEDRO de usuário e apenas do compartilhamento da porção de maconha por JESSICA e NILTON, assim não demonstrada a autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime do artigo 28 ou ao menos pelo direito de apelar em liberdade.

Já a defesa técnica de NILTON requer sua absolvição, ressaltando as divergências nas versões policiais e a insuficiência de provas da traficância. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de porte do artigo 28.

Folha de Antecedentes e certidão de distribuição estão nas fls. 81/87 e 88/95.

Fundamentação

Crime do artigo 35

Diante da manifestação do Ministério Público, titular da ação penal, pugnando pela absolvição do acusado, não há como acolher a pretensão acusatória inicialmente apresentada.

Segundo se entende, o sistema processual penal brasileiro tende ao modelo acusatório, conforme opção inequívoca da Constituição Federal e corolário do Estado Democrático de Direito, da estrutura e organização do Poder Judiciário e do Ministério Público e, sobretudo, da imparcialidade do juiz. Diante da manifestação do titular da ação penal, após o esgotamento da fase instrutória, impõe-se a absolvição quanto a esta imputação.

Crime do artigo 33

A existência e a autoria delitivas restaram parcialmente demonstradas pelas provas pericial, documental e oral produzidas.

As declarações dos policiais em juízo confirmam a apreensão de substâncias nos termos do auto de apreensão, em que o perito oficial detectou a presença de maconha e cocaína, o que se soma à confissão judicial dos acusados JESSICA, quanto à maconha, e PEDRO, quanto à cocaína (artigo 197 do Código de Processo Penal).

Contudo, segundo se crê, não há prova suficiente quanto a no sentido de que o destino da droga apreendida não fosse o consumo pessoal, mas a entrega a terceiros.

Nos moldes do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às

circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Para apreciação do vetor objetivo da natureza e quantidade da droga adota-se como parâmetro um consumo diário individual médio de até 2,5g de maconha (cerca de 2 a 4 cigarros) e de até 0,2g de cocaína, conforme a Portaria 94/1996 dos Ministérios da Justiça e da Saúde de Portugal, sugerida por Maria Tereza Uille Gomes, então Secretária de Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos do Paraná (Estudo Técnico para Sistematização de Dados sobre Informações do Requisito Objetivo da Lei nº 11.343/2006, 2014).

Tal quantidade é compatível com o uso semanal médio de 14 cigarros de maconha referido em pesquisa com 80 dependentes da maconha do ambulatório do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas da Faculdade de Medicina da USP (Hercilio Pereira de Oliveira Junior, Avaliação do perfil de comorbidades, gravidade da dependência e motivação para o tratamento em uma amostra de usuários de maconha que procuram tratamento, Mestrado, USP, 2010); e com o uso de até 2g por episódio relatado por 58% de 86 usuários de maconha atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010).

Quanto à cocaína, tal quantidade de consumo individual acima referido é compatível com o uso de 2g de cocaína por mês um dos vetores para a definição de dependência em pesquisa estadunidense que apurou, ainda, consumo médio mensal de 0,8g de cocaína entre todas as 2.349 pessoas que disseram ter consumido a droga entre 1991 e 1993 (Kevin Chen e Denise Kandel, Relationship between extent of cocaine use and dependence among adolescents and adults in the United States, Drug and Alcohol Dependence, v. 68, 2002), mas é subestimada frente ao uso de até 2g a 5g por episódio relatado por 47% de 87 usuários de cocaína atendidos no Centros de Atenção Psicossocial e no Hospital de Clínicas da Unicamp em Campinas (Karina Diniz Oliveira, Perfil sócio demográfico, padrão de consumo e comportamento criminoso em usuários de substâncias psicoativas que iniciaram tratamento, Mestrado, UNICAMP, 2010), de modo que aquele valor não deve ser tomado de modo absoluto e deve ser sopesado, por exemplo, com o grau de pureza da droga.

No caso, a quantidade de droga apreendida não é de todo incompatível com o que normalmente se destinaria ao consumo próprio de um usuário da droga, e infirma a versão acusatória. Particularmente quanto a PEDRO, sua condição de usuário vem corroborada pelos documentos acostados dando conta de sua internação em setembro de 2021 bem assim – e ainda que precariamente, reconheça-se – pelo depoimento de sua esposa.

Negados os fatos pelos acusados, o único elemento probatório no sentido da versão acusatória que veio aos autos foi o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Não há qualquer outra prova que possa ser confrontada com o depoimento e a ele se somar.

Ao que se entende, a presunção de legalidade do ato administrativo não se aplica à esfera penal, norteadas pela estrita presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), devendo a pretensão acusatória ser comprovada em juízo por elementos intersubjetivos.

Não se está a duvidar da veracidade dos depoimentos prestados a este juízo por quem cumpre nobre e corajosa função no sistema de segurança pública em uma sociedade brasileira tão desigual e fragmentada, mas o Estado de Direito exige algo mais para legitimar a privação de direitos.

Mutatis mutandis é o que levou o Superior Tribunal de Justiça a exigir mais do que a palavra dos agentes policiais para resultar válida a autorização de ingresso no domicílio, verbis: “7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas

autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação - como ocorreu no caso ora em julgamento - de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado." (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). Tal entendimento também foi sufragado pela Quinta Turma: HC 616.584/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021. Crer que a palavra dos policiais envolvidos na formação da opinio delicti seja suficiente para a condenação desde que não infirmados ou refutados pela defesa é impor indevida inversão do ônus probatório, que é da acusação, e violar, por via transversa, o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal (cf. Aury Lopes Jr., Direito Processual Penal, 18ª ed., Saraiva, 2021, p. 529-530). Afinal, em última análise, o destino do acusado já estaria selado tão somente pela atuação do agente policial.

No caso, a situação se agrava diante do quanto atestado pelas testemunhas. O policial civil João Paulo disse que, a fim de coibir o tráfico na praça central de Itariri, inclusive porque tinham feito trabalho antes mas o tráfico persistia. Pararam a viatura descaracterizada e observaram um homem negro, NILTON, e uma moça, com cabelo pintado loiro, JESSICA retirando algo do sutiã, entregava a NILTON que, recebia o dinheiro e entregava o objeto a terceiros adquirentes. Em dado momento da campanha, apareceu um usuário, NILTON conversou algo com JESSICA e ela montou na bicicleta e saiu da praça. O policial Luciano a acompanhou e, depois, lhe disse que ela foi até uma casa, entrou e saiu. Voltando à praça, entregou um novo objeto a NILTON. Fizeram, então, a abordagem e encontraram a droga. Viram que o objeto entregue por JESSICA era uma porção de maconha. Informalmente, JESSICA disse que foi até o imóvel para receber o dinheiro de venda de uma bicicleta, porém, o rapaz não estava lá. Foram, então, com JESSICA até a casa. Chegando lá, JESSICA chamou por Pedrinho, que perguntou, de dentro, se NILTON estava junto. Ele abriu a porta e os agentes se identificaram como policiais. PEDRO, então, disse que estava com 4 eppendorfs e que seria usuário, franqueando a entrada e a revista. Fizeram busca e encontraram em um estojo mais 11 eppendorfs de cocaína, 7 reais e algumas anotações de contabilidade do tráfico. Informalmente, PEDRO disse que JESSICA era uma conhecida sua, apenas, e lá não morava, mas encontraram o RG de JESSICA no local. Conduziram todos à Delegacia e uma policial feminina encontrou 90 reais no sutiã de JESSICA. Em outra diligência, algum tempo antes, talvez uma semana ou um mês, abordou NILTON no local, mas, naquela oportunidade, não perceberam nenhum movimento dele relativo ao tráfico - identificaram apenas outros dois indivíduos no comércio. Visualizaram NILTON, no dia, em ato de mercancia. O usuário - indivíduo visto uma única vez - que era atendido por NILTON quando da abordagem se evadiu e preferiram abordar os traficantes. Este usuário não chegou a pegar algum objeto com NILTON, pois a abordagem foi antes. Não se recorda das vestimentas. NILTON chamava JESSICA no sentido de olhar para ela e conversar com ela, mas estavam juntos. A campanha se deu a partir da outra extremidade da praça, a uns 30m dos acusados. A abordagem se deu já escurecendo e durante a noite. Identificaram os pinos azuis porque, durante

a campana, chegaram a descer do carro e conseguiram visualizá-los. NILTON ia entregar uma maconha ao usuário que se evadiu antes disso. JESSICA chegou na praça com uma sacola, mas não tinha nada dentro. Não sabe se rapidamente dispensaram alguma coisa. Trabalha há 11 anos na equipe especializada da polícia. Não foi apreendida droga em saquinho de chupe-çupe, segundo se recorda, mas apenas em pinos. Apreenderam 1 porção de maconha com NILTON e com JESSICA não havia nada. Na casa é que encontraram 4 mais 11 porções de cocaína com PEDRO. Presenciou na praça cerca de três transações e optaram pela abordagem na quarta transação. O adquirente da quarta transação ficou aguardando na praça enquanto JESSICA ia até a casa. Apreenderam a folha com anotação, mas não se recorda de seu conteúdo. Não conhecia JESSICA ou PEDRO.

O policial civil Luciano disse que iniciaram trabalhos na praça central de Itariri desde dias anteriores porque ali acontecia tráfico de drogas a vista de todos, deixando moradores e comerciantes em situações de medo. Fizeram uma campana, observando a movimentação e identificaram um casal, JESSICA, mais loira, e NILTON, vendendo a droga. NILTON ficava sentado em um banquinho, era abordado por alguns usuários e recebia o dinheiro; JESSICA ficava andando e ia até NILTON quando ele a chamava, tirava algo de dentro da parte de cima da roupa e entregava a ele, que passava ao usuário. Ora NILTON guardava o dinheiro no celular e ora entrega para que JESSICA guardasse nas suas vestes. Em determinado momento, JESSICA pegou sua bicicleta e foi para atrás da praça, o que despertou interesse dos policiais para se saber onde era armazenada a droga. Em um segundo momento, JESSICA repetiu o movimento com a bicicleta e foi seguido pelo depoente, que viu quando ela entrou em um imóvel com várias habitações para alugar. Ela entrou no último. No retorno, ela foi ao encontro de NILTON e decidiram abordá-los no momento da entrega do objeto ao usuário. Adotando o mesmo modus operandi, JESSICA entregou um objeto a NILTON, que iria servi-la a um usuário, quando feita a abordagem. O usuário acabou saindo, se perdendo em meio à multidão. Informal e inicialmente, NILTON negou o tráfico e JESSICA disse que tinha vendido uma bicicleta ao indivíduo e que não morava no local. Foram, então, até o imóvel e, lá chegando, JESSICA bateu na porta e alguém de dentro perguntou quem era, quando ela se identificou e disse que NILTON não estaria junto. No momento em que o rapaz abriu a porta, se identificaram como policiais e indagaram se JESSICA morava ali, o que foi negado. De pronto, PEDRO disse que tinha 4 pinos de cocaína, somente, e franqueou a entrada. Em revista, encontraram no quarto um estojo escolar com mais 11 pinos. Posteriormente, encontraram documentos e roupas femininas, bem assim saquinhos para embrulho da droga. Apesar da forma organização, tendente a confundirem-se com usuários, concluíram se tratar de traficantes. Conduziram, então, todos à Delegacia e, lá, encontraram 90 reais com JESSICA. Ressalta que, dias antes, realizou outra operação em que prenderam um rapaz e NILTON estava no meio, mas não constataram, na época, a efetiva participação sua no comércio. O estojo com os 11 pinos foi encontrado no quarto de PEDRO. Visualizou, na praça, atos de mercancia, com NILTON repassando o entorpecente aos usuários e JESSICA lhe servia de apoio, provavelmente ficando com poucas porções. No momento da abordagem havia um usuário, que se evadiu, porque na praça há sempre um tumulto. Priorizaram deter os responsáveis pelo tráfico quando se deu o corre-corre após a identificação da equipe policial. Chegaram por volta das 17h30 da tarde e observaram a ação, fazendo a abordagem já no final do dia. Não se recorda das vestimentas do usuário que se evadiu, mas que era magro. Isto por se focar em quem é responsável pelo tráfico. Viu JESSICA adentrar o imóvel em que estava PEDRO e retornar com uma sacola plástica na bicicleta. Optou por não realizar a abordagem antes, apenas JESSICA com a sacola, para concluir a operação e saber da exata movimentação do comércio. A equipe era formada pelo depoente e por seu companheiro. Quando JESSICA retornou, tirou algo de dentro da sacola e entregou a NILTON, o que depois constataram se tratar de maconha. Aliás, tentaram jogar fora porque NILTON o conhecia de dias atrás. JESSICA, naquele momento, não estava com cocaína. A droga foi encontrada nas mãos de NILTON e na capinha do celular só havia dinheiro. Fizeram a campana a uns 20m. No momento da abordagem já estava escuro, mas o início dos trabalhos foi mais cedo. Os eppendorfs foram encontrados dentro da casa, mas, no momento em que estava claro, viram um objeto azul sendo entregue,

durante o dia. Na sacola plástica não havia mais nada. Como já tinham feito um trabalho há alguns dias, acredita que os traficantes mudaram o modo de agir, por isto estavam com tão pouca droga, dificultando a ação policial. A cocaína de dentro do estojo foi encontrada em sacos de chupe-chupe, assim como a maconha, e encontraram mais embalagens vazias dentro do imóvel. Não localizaram maconha dentro do imóvel de PEDRO. A diligência anterior na praça foi na quinta ou sexta-feira anterior, tendo prendido RENATO e outro indivíduo, se não se engana.

Ora, se se tratava de ponto conhecido de venda de drogas e se os policiais organizaram previamente a realização de campana, era de todo possível a produção de outros elementos probatórios, como fotografias ou filmagens da ação criminosa, senão da própria abordagem.

Depois, não se pode ignorar ser ao menos inusitada a manutenção de tão pouca quantidade de droga para o comércio, tendo JESSICA, segundo a narrativa policial, ido buscar com PEDRO 1 única porção de maconha para entregar ao adquirente. Também inusitada é a abordagem de PEDRO, dizendo os policiais que ele teria perguntado, através da porta, se JESSICA estaria com NILTON. A finalidade deste diálogo é de todo nebulosa se, na dinâmica constatada pelos policiais, JESSICA iria sozinha para o local de abastecimento. E este é o único elemento concreto que liga PEDRO e a (pouca) droga em sua casa a NILTON.

Em suma, a respeito deste elemento do tipo penal, o titular da ação penal não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, restando dúvida quanto a este aspecto da responsabilidade penal do acusado. Assim, não afastada a presunção de inocência a todos assegurada pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, corolário de um Estado Democrático de Direito, impõe-se o afastamento da pretensão neste particular.

Adequação Típica

Como se disse, o quadro probatório evidenciou que JESSICA e PEDRO praticaram, de forma consciente e deliberada, a conduta de transportar e trazer consigo droga para consumo pessoal, nos exatos termos do artigo 28 da Lei 11.343/06.

Daí porque, nos termos do artigo 383, caput, do Código de Processo Penal, acolho em parte a pretensão acusatória e atribuo qualificação jurídica diversa à denúncia para reconhecer a prática do crime de porte para consumo pessoal.

Prevista na lei penal, a conduta do acusado também é materialmente típica, pois causa expressiva lesão, ainda que potencial, ao bem jurídico penalmente protegido. Por consequência, a severa intervenção penal não viola o direito constitucional à liberdade, atendido o postulado da proporcionalidade.

Observo que não há incompatibilidade entre o preceito do artigo 28 da Lei 11.343/06 e a Constituição Federal, mesmo que sob o pálio do princípio da alteridade. Não há dúvida de que o direito penal deve observar se nortear pelo princípio da alteridade ou transcendentalidade, mas o que é observado por esta norma penal, que não pune o consumo de drogas, mas o seu porte com destino ao consumo pessoal, assim com potencialidade de circulação, gerando um perigo à saúde pública.

Para PEDRO incide a agravante da reincidência, nos termos dos artigos 61, inciso I, e 63 do Código Penal, cuja constitucionalidade já foi assentada pelo Supremo Tribunal Federal com repercussão geral (RE 453000, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2013).

Com efeito, o acusado já havia sido condenado, com trânsito em julgado, por fatos anteriores ao caso vertente, nos seguintes feitos: autos nº 0011313-

13.2014.8.26.0019, crime do art. 171 em 05/03/2013, com trânsito em 14/09/2016 e cumprimento da pena em 2019; autos nº 0000106-73.2015.8.26.0280, crime do art. 331 em 25/01/2015, com trânsito em 27/11/2020.

Ilícitude e Culpabilidade

Presente a tipicidade, não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que a conduta tenha sido praticada em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou em exercício regular de direito, o que excluiria a ilicitude da conduta, de acordo com o artigo 23 do Código Penal.

À época dos fatos, o réu era maior de 18 anos, atendido o critério constitucional de imputabilidade (artigo 228 da Constituição Federal); e era plenamente capaz de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse

entendimento, sem que haja elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que não tivesse plena saúde mental, estivesse fortuitamente embriagado ou sob o efeito de substância psicoativa ou, ainda, sob dependência de droga (artigos 26 e 28 do Código Penal e do artigo 45 da Lei 11.343/2006).

Por fim, culturalmente inserido na sociedade brasileira, o réu tinha ao menos potencial consciência da ilicitude e não há elementos a indicar ou a criar séria dúvida de que lhe fosse inexigível conduta diversa, por estar sob coação irresistível ou agir em estrita obediência a ordem (artigo 22 do Código Penal).

Dosimetria

Passo à individualização da sanção penal exigida pelo artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, com as particularidades inerentes às penas do artigo 28 da Lei 11.343/06.

O nível de consciência do injusto e o grau de exigibilidade de comportamento diverso (cf. Juarez Cirino dos Santos, Direito Penal – Parte Geral, 5ª ed., 2012, p. 518-519) não destoam da culpabilidade já pressuposta na caracterização do crime. Os acusados não ostentam maus antecedentes, inexistindo condenação criminal transitada em julgado a ser valorada nesta fase, conforme exige a presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), nos moldes da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça e da tese com repercussão geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal (RE 591054, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 17/12/2014).

Nada de desfavorável se comprovou a respeito da conduta social dos acusados, o que, de qualquer modo, só justificaria sanção penal mais gravosa em função da prevenção especial positiva, prejudicada ante o “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas” no sistema penitenciário brasileiro (STF, ADPF 347 MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). Não tendo o titular da ação penal, neste ponto, se desincumbido do ônus probatório que lhe competia, de rigor considerar favorável a conduta social do acusado, em atenção ao in dubio pro reo (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Não há elemento probatório seguro a respeito da personalidade dos acusados, o que é questão técnica complexa e de, no mínimo, duvidosa convencionalidade (v. Corte Interamericana de Direitos Humanos, Fermín Ramírez vs. Guatemala, julgado em 20/06/2005).

Os motivos e as circunstâncias do crime não destoam do que é acobertado pelo tipo penal e não justificam imposição de sanção mais branda ou mais severa.

As consequências do crime são igualmente neutras, nesta fase, diante da extensão relevante, mas não excessiva, de atingimento ao bem jurídico tutelado.

A natureza e a quantidade da droga não são expressivas a ponto de justificar a elevação da pena, mas, ao contrário, são mínimas para JESSICA.

Por tudo isto, considero favorável a conduta social e, para JESSICA, a natureza e quantidade da droga e neutras as demais circunstâncias.

É de rigor, ainda, a atenuação da pena em razão da confissão (artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal) e o agravamento, para PEDRO, por força da reincidência (artigo 65, inciso I, do Código Penal).

Assim, suficiente e adequada a aplicação a JESSICA da pena de advertência sobre os efeitos das drogas.

Para PEDRO, necessária e adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas.

Via de regra, realmente inviável a detração de que trata o artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, remetendo a questão ao juízo da execução. Com efeito, o preceito incluído pela Lei 12.736/12 confunde os institutos diversos da fixação do regime inicial e da progressão de regime e, deste modo, viola a Constituição Federal, que consagra a individualização da pena e a isonomia (artigo 5º, caput e incisos I e XLVI).

Contudo, excepcionalmente na hipótese vertente, em que a sanção penal ao final

aplicada é a de advertência e a de prestação de serviços à comunidade – e cujo descumprimento leva, em último caso, à imposição de multa –, impõe-se desde logo reconhecer a extinção da punibilidade pelo seu cumprimento por força da detração, diante do tempo de prisão, no regime fechado da preventiva, em razão deste processo.

Contabilizo, analogicamente, o equivalente a 1/3 do prazo da prestação de serviços em comparação ao tempo da prisão preventiva, assim cumprida a pena 1 mês após o cumprimento do mandado de prisão preventiva. E contabilizo, por apreciação equitativa, o equivalente a 1 dia de prisão, assim cumprida a pena no mesmo dia do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

Efeitos secundários da condenação

Considerando demonstrado apenas a destinação ao consumo pessoal da droga, não há que se falar em perda do produto do crime, liberando-se o dinheiro apreendido em favor dos acusados.

Dispositivo

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão acusatória para absolver NILTON PINHEIRO JUNIOR da imputação da prática dos crimes dos artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, incisos V e II, respectivamente do Código de Processo Penal; absolver JÉSSICA BATISTA RIBEIRO FRANCISCO e PEDRO HENRIQUE MOTA DE SOUZA da imputação da prática do crime do artigo 35 da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal; condenar JÉSSICA BATISTA RIBEIRO FRANCISCO à pena de advertência, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06; e condenar PEDRO HENRIQUE MOTA DE SOUZA à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 3 meses, em programas comunitários, entidades educacionais ou assistenciais, hospitais, estabelecimentos congêneres, públicos ou privados sem fins lucrativos, que se ocupem, preferencialmente, da prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, pela prática do crime do artigo 28, caput, da Lei 11.343/06. Em razão da detração, julgo extinta desde logo a punibilidade de JESSICA e PEDRO, pelo cumprimento das penas impostas.

Expeça-se alvará de soltura clausulado, com urgência.

Custas

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno JESSICA e PEDRO ao pagamento das custas processuais (artigo 4º, parágrafo 9º, alínea 'a', da Lei Estadual 11.608/03). A gratuidade é questão a ser apreciada em momento oportuno, pelo juízo da execução, se o caso.

Providências Finais

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Instituto de Identificação Civil (artigo 709 do Código de Processo Penal); atualize-se o histórico das partes no cadastro processual com a respectiva anotação; e expeça-se a certidão de honorários ao advogado dativo, se o caso.

Ainda com o trânsito em julgado, determino a destruição das amostras da droga guardadas para contraprova, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06, comunicando-se à autoridade policial.

Após, arquivem-se definitivamente.

Int.

Itariri, 26 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA